

基本権と「公共の福祉」及び平等保障の法理

海野 敦史

「公共の福祉」と基本権の制約

憲法上の「公共の福祉」

【憲法12条】

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に**公共の福祉**のためにこれを利用する責任を負ふ。

【憲法13条】

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、**公共の福祉**に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

【憲法22条 1 項】

何人も、**公共の福祉**に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

【憲法29条 2 項】

財産権の内容は、**公共の福祉**に適合するやうに、法律でこれを定める。

内在的制約と外在的制約

- ・ 内在的制約とは、基本権ないし憲法規範自体に内在する制約。
- ・ 外在的制約とは、社会全体の利益等を確保する観点からの外からの政策的な制約。

基本権の保障と「公共の福祉」との関係をめぐる主な学説(Ⅰ)

一元的外在制約説（今日では少数説）

- ・原則としてすべての基本権に「公共の福祉」による外からの制約を認めるもの。
- ・基本権は憲法12条・13条に基づき「公共の福祉」と調和する限りで尊重されると解釈。
- ・憲法22条・29条が「公共の福祉」を再言しているのは特別な法的意味を有しないと解釈。

内在・外在二元的制約説

- ・「公共の福祉」により外在的・政策的に制約されるのは、憲法22条・29条に基づく経済的自由権のみと解釈。
- ・その他の基本権は内在的な制約が存在するにとどまると解釈。
- ・憲法12条・13条は訓示的規定で特別な法的効力を有しないと解釈。

⇒憲法13条に基づく幸福追求権を訓示的規定とみるのでは、「新しい基本権」の芽を紡ぎ取るとの批判。

基本権の保障と「公共の福祉」との関係をめぐる主な学説(2)

一元的内在制約説

- ・「公共の福祉」を基本権相互間の矛盾・衝突を調整する原理と解釈。
- ・すべての基本権は「公共の福祉」を根拠として制約され、自由権の制約については「自由国家的公共の福祉」（必要最小限度の規制のみ）として作用し、社会権の保障のために自由権の制約を根拠づける場合には「社会国家的公共の福祉」（必要な限度の規制）として作用と解釈。
- ・憲法22条・29条が「公共の福祉」を再言しているのは特に制約を受けやすいからと解釈。

⇒実際に立法の合憲性を判断するのが困難、外在的制約との境界が不明確との批判。

新内在・外在二元的制約説（今日の多数説）

- ・「公共の福祉」は基本権の一般的な制約根拠であるが、それ自体は制約の正当化事由となるものではないと解釈。
- ・制約の正当化事由は個々の基本権の性質に応じて具体的に引き出されなければならない。
- ・憲法22条・29条が「公共の福祉」を再言しているのは外在的制約が妥当する機会が多いからと解釈。

基本権の保障と「公共の福祉」との関係

検討

- ・「公共の福祉」の確保の必要性は、基本権の制約の一次的な根拠となるが、基本権の行使を調整する公権力に対する「統制のルール」として実質的に機能。
- ・営業の自由や財産権は「立法による内容形成」の余地が特に大きいことから、その内容形成が憲法適合的な形（「公共の福祉」に反しない形）で行われることを確保するために「公共の福祉」が憲法22条・29条で再言されていると考えられる。

【参考】

- ・憲法22条1項は、職業選択の自由のみならず、職業遂行の自由（職業活動の自由）、ひいては営業の自由を保障するものと解されている（最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁）。
 - ・営業の自由を保障する意義は、国民生活にとって不可欠となる基本的な財・役務に関する営業活動が一定の規律の下で円滑に行われ、国民が個人の自律（憲法13条）を確保しつつ「健康で文化的な最低限度の生活」（憲法25条1項）を営むことができるようにすること。
- ⇒ 営業の自由には、事業者の主観的権利を保障する側面だけでなく、公権力が一定の競争政策や消費者の保護等の措置を適切に講ずることを求める客観法的側面がある。
- ・憲法29条2項により、財産権は立法による内容形成が予定されている。ただし、同条1項で財産権の不可侵が定められていることから、立法権によっても侵すことのできない権利の範囲が予定されている。

【参考】チャタレイ事件判決（最大判昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁）

- ・ 公共の福祉に反するか否かは、客観的に判断すべきものであり、各人の自主的判断に委ねられるべきものではない。

憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである。

この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり、論旨は理由がない。

「公共の福祉」の機能

公権力の統制

- ・基本権（幸福追求権＝包括的基本権）の「最大の尊重」は、基本権に対する「公共の福祉」に基づく制約について、憲法適合的な目的の下でその手段が必要最小限度なものとなっており、かつ当該目的と均衡するものであることを要請。
 - ⇒「最大の尊重」の要請自体に、公権力の行為を統制し、権利行使の最適化を確保する**比例原則**の考え方が組み込まれていると解される。
- ・同時に、基本権の「最大の尊重」は「公共の福祉に反しない」ものとなることが求められており、それを確保するのは公権力の役割。
 - ⇒公権力においては、「**公共の福祉**」を**確保する義務**がある。必要に応じて立法等を通じて適切な調整措置を講じることが必要（国民の基本権の行使に対して「最大の尊重」を理由として、完全に「野放し」にすることは許されない＝**過少介入の禁止**）。
 - ⇒**基本権の「最大の尊重」と「公共の福祉」の確保との適切なバランス**を図ることが求められている。
 - ⇒基本権の「最大の尊重」を図るうえでは、立法による「基本権の内容形成」も必要となり得る。その場合、立法裁量の限界が問題となり得る（内容形成に当たっては、立法権によっても侵すことのできない基本権の核心部分を特定することが重要）。

基本権の制約の正当化

制約の方法とその正当化の論証

- ・基本権の制約は、原則として法律に根拠を有する必要。
- ・よって、その法律の規定は明確である必要。その明確性は、「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合における当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」（最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁）により決まるとされる。
- ・ただし、法律の執行者が処分等の形式で基本権を制約することもあり得る。法律の趣旨から外れた基本権の制約が行われれば、違憲な執行と捉えられる。
- ・立法者が、行政等の執行者に委任できない事項まで委任することも違憲となり得る。
- ・「公共の福祉」は基本権の制約の具体的な正当化事由とはならず、当該制約が「公共の福祉」に適合しているか否かの論証に解消できない以上、その論証は別の観点から検討される必要。

⇒ 比例原則に基づく比較衡量の審査。

基本権の制約の正当性の審査（比例原則）

目的審査

- ・基本権の制約は正当な規制目的を前提。ゆえに、正当な規制目的の存在や不当な規制目的の有無を審査。
- ・規制目的が一定の弊害の防止にある場合には、弊害の有無やその発生の蓋然性についても審査。

手段審査

- ・基本権の制約は正当な規制手段をも前提。ゆえに、規制手段の正当性や不当な規制手段（奴隷的拘束、拷問・残虐な刑罰、検閲等）の有無を審査。

狭義の比例性審査

- ・規制の手段と目的とが適切な関係にあるか否かを審査（比例原則）。
- ・①規制手段が規制目的と合理的に関連（適合性）、②規制手段が規制目的の達成にとって必要最小限度（必要性）、③規制手段の導入により得られる利益と失われる利益とのバランスが均衡（狭義の比例性＝比較衡量）。③の比較衡量の客観性を確保することが課題。

【参考】薬事法事件判決(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)

- ・ 憲法22条1項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。(中略)このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがって、右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。

規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。

この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性和合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭がありうるのであつて、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものといわなければならない。

憲法14条1項の保護法益(Ⅰ)

憲法14条1項の規定

すべて国民は、**法の下に平等**であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、**差別されない**。

憲法14条1項の保護法益をめぐる学説

【有力説】

- ・ 公権力に対して不平等な取扱いの禁止を義務づける客観的法規範（**平等原則**）。
- ・ 国民に「差別されない権利」という主観的権利を保障（**平等権**）。

※「平等」が関係性を前提とした概念であることから、平等権を実体的権利とは異なる手続的権利と捉える学説もある。

【異説】

- ・ 「平等」は一定の実体的な権利・利益の存在を前提とすることから、その権利・利益から独立した権利を導くものではなく、「平等権」を観念することは不要。

憲法14条1項の保護法益(2)

検討

- ・ 一般に、基本権に関する規定は、客観的法規範の存在を前提として、主観的権利の個別化を行う余地が認められる場合に、その権利が憲法上の権利として観念される。
⇒「個別化」の契機の有無を見極めることが重要。
- ・ 平等原則が一定の客観的な「状態」の実現を保障しようとしているのに対し、平等権は公権力の不当な差別行為の排除を求めることがその実体⇒「平等権」を観念。

【平等原則とは異なる主観的権利として平等権を措定する必要性】

- ① 事実状態で同一とみなされる二者のうち、一方が他方よりも優遇されている場合、平等原則に対する違反が客観的に認められても、優遇されている者は自己の平等権の「侵害」を主張することは困難。

⇒基本権の「侵害」は一定の不利益な状態の発生を前提に成立。優遇されている者には不利益状態の発生が認められない。

⇒平等原則は一定の客観的な状態の確保を指向。平等権は同一の条件を有する他人との比較を前提として自らが相対的に不利な立場におかれて初めて主張可能。

憲法14条1項の保護法益(3)

② 公権力から「政治的、経済的又は社会的関係」において冷遇された者は、単に「不当な区別」を受けたということにとどまらず、ある種の「劣等の烙印」を押されることにより、「個人の尊厳」が傷つけられ得る。

⇒ 「劣等の烙印」は、平等原則との関係においては派生的・付随的に生じる効果であるとも言えるが、平等権との関係においては権利侵害の直接的な効果。

⇒あらゆる局面で、他人と比較して差別的に取り扱われない、蔑視の念に基づく「差別」から解放されるという法益それ自体が、個人の人格的自律を支える機能。

③ 私人による「平等権に関する法益」に対する救済が問題となる可能性。

⇒企業等の私人により、特定の個人・集団が差別的取扱いを受ける場合、私的自治の原則を踏まえれば、公権力がそれに対して制度的な手当てを行わなかったとしても、その不作為をもってただちに平等原則違反となるわけではない。

⇒差別的取扱いを受けた個人・集団は、仮に平等権を享有しないのであれば、公権力に対して上記差別的取扱いからの保護を主張することが困難となる可能性。

※一定の条件下において、私人による侵害からの保護を公権力に対して求める余地。

憲法14条1項の保護法益(4)

個別の基本権との関係

- ・ 憲法13条が包括的基本権を定めていると解されることを踏まえれば、多くの場合、平等権の内実はいずれの基本権の保障内容に「吸収」され得る。
- ・ しかし、ある基本権に対する制約となる措置が、それ単体としてみれば、その目的や手段に照らして「侵害」とは認められない状態であっても、他の国民に対する措置との比較で「差別」として認められる場合はあり得る。
- ・ また、「差別」が単なる「不当な区別」にとどまらず、「劣等の烙印」を押すことに伴う社会的地位の低下等を招く効果をもたらすとすれば、こうした弊害を含意する「差別」という行為に対する固有の防御権の領域を觀念することが可能。

※ 差別感情に基づく行為を受けない権利としての平等権

⇒主観的権利としての平等権を定立する意義がある。

「平等」の意義(Ⅰ)

学説

【あらゆる局面において各人を均等に取り扱うという意味での**絶対的平等**と、同一の事情・条件の下では同様に扱うという意味での**相対的平等**との区別】

- ・通説は、各人はその事実状態において千差万別で、絶対的平等を貫くとかえって不合理な結果をもたらすことになるため、「平等」を相対的平等と解釈。
- ・判例も、各人には「経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異」から生ずる不均等が存在するが、それが「一般社会観念上合理的な根拠に基づき必要と認められるものである場合」には、平等原則に反しないと説く（最大判昭和39年11月18日刑集18巻9号579頁）。
- ・このような考え方の下では、事実状態の差異に相応した法的な取扱いが憲法上許容されるところ、異なる取扱いが行われる場合にそれが社会通念からみて合理的である限り、平等原則に違反しないこととなる。
- ・その場合、何が「事実状態の差異」となるか、また何が「合理的」であるかの基準は一義的に特定困難で、各人間のどのような相違に着目し、どのような権利・利益に対して、異なる取扱いがどの程度許容されるのかということを個別に要検討。

※「平等」には人格的価値の次元での平等と、各人の事情を踏まえた具体的措置の次元での平等とがあり、前者は後者よりも厳格な違憲審査基準で区別の合理性が判断されるべきであるという旨を説く学説も。

「平等」の意義(2)

検討

- ・ 同一の条件を有すると認められる他人との比較において、憲法13条の個人の尊重の原理に反する法的取扱い（区別）には合理性が認められず、禁止される「差別」となる。
- ・ よって、個人の尊重の原理に照らしつつ、各人の相違に即して合理的に行われる区別は「差別」とはならないと考えられるため、憲法14条1項にいう「平等」とは相対的平等を意味するものと解される。
- ・ 憲法の要請する「平等」の趣旨を一義的に確定できなくとも、平等原則が総則的位置づけに基づく以上、むしろ個々の権利・利益の保護法益に応じたきめ細かな個別判断が予定されており、それ自体が問題となるわけではない。
- ・ 他方、各人の「個人の尊厳」及び人格的自律との関わりの程度に応じて、求められる「平等」の範囲を画することは可能かつ合理的。
- ・ 相対的平等には一定の相対性ないし「幅」がある中で、公権力の区別行為が当事者にもたらす影響に照らし、「個人の尊厳」及び人格的自律との関わりの深さが強いほど、より画一的な取扱いが要求される（許容される区別の「幅」が狭い）ものと解される。

「平等」の意義(3)

学説

【法律上の均一的な取扱いという意味での**形式的平等**（機会の平等）と事実関係の均一という意味での**実質的平等**（結果の平等）との区別】

- ・かつては、実質的平等を憲法14条1項の「平等」に含める考え方が有力。なお、判例は、従前から形式的平等論によっているとされる（最大判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁）。
- ・「実質的平等の要求と形式的平等の要求は同次元では両立しない」という認識を踏まえた今日の多数説は、形式的平等の実現が原則であるが、同時に一定の合理的な理由に基づく異なる取扱いが認められる範囲内で実質的平等が考慮されると主張。
- ・実質的平等の観念を徹底させる立場からは、平等権には、実質的平等を実現するために公権力に一定の作為を要求できる積極的権利としての側面が備わっており、社会全体の秩序の中で「平等」の実現への配慮が公権力に対して求められると主張。
⇒立法を通じた**積極的差別解消措置**（アファーマティブ・アクション）を憲法上の要請と捉える理解に接続。その場合、「合理的な配慮の不提供」も不作為による「差別」として平等権の侵害となり得ることに。
- ・実質的平等の実現は生存権をはじめとする社会権に関する措置により行われるのが基本で、積極的差別解消措置については「逆差別」を招来し得るとする批判も。

【参考】夫婦同氏制判決(最大判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁)

- ・憲法14条1項は、法の下での平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである（中略）。

そこで検討すると、本件規定（作成者注：婚姻の際に夫婦の一方は他方の氏を称することによって氏が改められるとする民法750条の規定）は、夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって、その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく、本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。

我が国において、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが、**本件規定の在り方自体から生じた結果**であるということとはできない。

したがって、本件規定は、憲法14条1項に違反するものではない。

もっとも、氏を選択に関し、これまでは夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている状況にあることに鑑みると、この現状が、夫婦となろうとする者双方の真に自由な選択の結果によるものかについて留意が求められるところであり、仮に、社会に存する差別的な意識や慣習による影響があるのであれば、その影響を排除して夫婦間に**実質的な平等**が保たれるように図ることは、憲法14条1項の趣旨に沿うものであるといえる。

【民法750条】

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

「平等」の意義(4)

検討

- ・ 相対的平等を憲法の要請と捉える以上、形式的平等と実質的平等とを二律背反的に捉えるべきではなく、相対的平等を実現するための手段として位置づけるべき。
- ⇒ 相対的平等の確保のために、形式的平等に基づく取扱いと実質的平等に基づく取扱いとの適切なバランスが図られるべき（合理的根拠が認められない場合には形式的平等に基づく取扱い、合理的根拠が認められる場合には実質的平等に基づく取扱いを指向）。
- ・ 実質的平等は相対的平等の確保に必要な範囲で指向されると解する限り、「政治的、経済的又は社会的関係」のすべてで、もっぱら実質的平等の確保の必要性からただちに積極的差別解消措置の実施を求める積極的権利が指定されると解することは困難。
- ・ ただし、（相対的平等の確保のために）実質的平等の確保の必要性が一定の範囲で認められる限り、その必要性に適合する一定の積極的差別解消措置の実施を（比例原則を充足する範囲内で）憲法上の要請とみる余地は生じ得る。

「法の下に」の意義（Ⅰ）

学説

- ・かつては、法の適用の局面における平等を指すのであって、法の内容における平等を指すものではなく、立法権を拘束しないと解する考え方（**立法者非拘束説**）が有力。
 - ・今日の通説は、国政全般にわたる平等を指すものと解する考え方（**立法者拘束説**）。
 - ・一般私人による差別的取扱いにまで及ぶのかということについては、憲法が本来公権力を規律するものであることから、一般に否定的。
- ※ 判例も、「もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」と説示。
- ・近年は、「法の下に」には絶対的平等を否定する意味合いが込められており、「法の下での平等」とは、正当なものとして構成された立法目的に適合しない「合理的根拠に基づかない区別」を禁止するものと解する見解も提示。

「法の下に」の意義(2)

検討

- ・立法の段階での「平等」が確保されていなければ、その適用の局面の「平等」が無益なものになりかねないこと、裁判所に違憲立法審査権が付与されていること（憲法81条）等から、立法者拘束説の考え方は妥当。
 - ・憲法14条1項にいう「法」には憲法規範が含まれるのであって、「法の下での平等」は基本的に立法権を含む公権力全般に対する規律であると解される。
- ※ 原則として自由権の享有主体である一般私人にその効力が直接及ぶものではないが、「準公権力」としての通信管理主体（通信事業者等）が個々の「通信」を取り扱う場合には、一般私人の場合とは異なる別途の考慮が例外的に必要。
- ・「平等」の原意は各人の均等であり絶対的平等であると考えられるところ、「法の下」という限定は、これに「法」による一定の相対性（結果的な不均等）の余地を示したものと解することが可能。
- ⇒ 近時の学説が「法の下に」と相対的平等とを結びつけて解釈していることは、十分な合理性がある。

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」の意義（Ⅰ）

学説

- ・ 限定列举事由に該当しない事由であっても「差別」は許されないと解されている。
- ・ 限定列举事由を単なる例示とみるか（**例示列举説**）、「差別」に関して特に疑わしい事由とみるか（**特別事由説**）かで学説の対立。近年の学説は特別事由説が有力。
- ・ 判例は、「平等」を論ずる際に「職業」等の限定列举事由以外の事由を用い（最大判昭和25年10月11日刑集4巻10号2037頁参照）、限定列举事由について「例示的なもの」としていること（最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁参照）から、例示列举説によると考えられる。
- ・ 特別事由説にも、限定列举事由による差別には原則として違憲性が推定されると解する考え方、合憲性の主張者に合理的取扱いであることの立証責任が課される（限定列举事由以外の事由による「差別」は合憲性の推定が作用する）と解する考え方、各限定列举事由には不合理とされる固有の事情があり得るため個別の分析を要すると解する考え方等の相違。
- ・ 特別事由説に対しては、限定列举事由以外の事由について、合理性を容易に認めてしまうのは妥当ではないとする批判も有力。これによれば、人種、社会的身分、門地等の先天的な事情と信条という後天的な事情とは明確に区別されるべきであるとされる。

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」の意義(2)

検討

- ・ 例示列举説であれ特別事由説であれ、限定列举事由による「差別」は禁止されるし、限定列举事由による場合であってもそれ以外の事由による場合であっても、合理的根拠が認められる正当な区別については禁止されない。
⇒例示列举説と特別事由説との対立は相当程度相対化。
- ・ 憲法が明文で掲げる列举事由については、特に慎重な判断が認められる要素であると捉えることが妥当と考えられる。
- ・ 公権力が行う区別の合理的根拠の有無については、区別事由と「個人の尊厳」との関わりを含め、問題となる権利・利益の具体的な趣旨を十分に踏まえた個別の検討が必要

「差別」の意義(Ⅰ)

学説

- ・ 伝統的な学説は、個人の尊重の原理や民主主義の原理に照らし、不合理な理由に基づくものと認められる区別に限定して捉えてきたが、近年の学説は、不合理な区別という意味合いを超える「差別」の概念を措定。
- ・ 個人の尊重の原理に背反する差別的意図に基づく行為については、一次的には各人間での異なる取扱いを行うものではなくても、「差別」に該当し得るとする考え方。
⇒この考え方によれば、「差別されない」という規定には、公権力が一定の差別感情に基づいて行動してはならず、差別的メッセージの発信を追及する主張に対しては誠実に対応することを義務づけるという趣旨が含まれている。
- ・ より包括的に「差別」概念を確立しようとする立場から、差別を助長する効果・影響を有する公権力の行為は、それを正当化する十分な理由がない限り、「差別」となるとする考え方。
⇒この考え方によれば、公権力が差別的意図に基づかずに行う行為であっても、また立法上は特定の集団に対する不利益となる規定となっていなくとも、それが差別を助長するインパクトをもたらす場合には違憲となり得る。

「差別」の意義(2)

- ・過去の差別の影響により構造的な地位の格差が残存している場合には、均等取扱いがかえって不均等な結果を助長し得ることから、このような形での「間接差別」についても「差別」に該当するものとして捉えるべきであるとする考え方。

⇒この考え方によれば、「構造的な地位の格差」を是正する観点からは、積極的差別解消措置の実施が求められる可能性が高まる。

検討

- ・「差別」には、差別的意図に基づく行為や差別を助長する効果を有する行為（間接差別を含む）が含まれ得るが、当該意図・効果を見極めるには、主観的な価値判断を伴うことが多いため、それらを正当化する合理的根拠の有無を総合的に判断することが必要。

⇒「差別」の射程は広範に捉え、区別の正当化事由について、制約される権利・利益の趣旨のほか、行為の意図やその波及効果も考慮しながら的確に特定することが重要。

- ・区別の正当化事由としての合理性については、基本的には、立法措置等の目的の合理性と当該目的を達成するための手段の合理性との双方の観点から検討される必要。

- ・（権利・利益の侵害ではなく）もっぱら他人との比較における平等性のみが問題となるような局面（特定の者の優遇等）では、区別の合理性が目的・手段の妥当性と一体化していることも多いことから、端的に区別の合理性を追求することが適当な場合も。